

1501203-03.2022.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gisela Ruffo

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... seria conhecido como um "ponto de tráfico" não é presunção absoluta do envolvimento do réu na prática do crime, eis que, nesses lugares, circulam tanto indivíduos que se dedicam ao comércio de drogas quanto usuários das substâncias. E o vídeo juntado aos autos também não demonstra, efetivamente, a vinculação do réu ao tráfico, eis que se trata de uma gravação efetuada a uma ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

4ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Alemães, Piracicaba - 13417-901 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501203-03.2022.8.26.0599 - Controle nº 2022/001026

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2216032/2022 - GOE-DEIC-DEINTER 9

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DARLIN ALVES RODRIGUES

Réu Preso

Aos 12 de dezembro de 2022, às 16:20h, através de videoconferência na aplicação Microsoft Teams, nos moldes do Comunicado CGJ nº 284/2020 e em observância ao disposto no Provimento CSM 2651/2022, realizou-se a presente audiência, sob a presidência da MMª. Juíza de Direito, Dra. Gisela Ruffo, comigo Escrevente ao final nomeado.

Representante do Ministério Público: Dra. FERNANDA GUIMARÃES ROLIM BERRETA - PRESENTE (via videoconferência)

.

Réu: DARLIN ALVES RODRIGUES - PRESENTE (via videoconferência)

Defensor Público: Dr. RAFAEL BRESCIANI MARRACINI - PRESENTE (via videoconferência)

Testemunha comum: PC MARCIO LUIZ TEIXEIRA DE CAMARGO BARHUN - PRESENTE (via videoconferência)

Testemunha comum: PC PAULO AFONSO CARDOSO - PRESENTE (via videoconferência)

Iniciados os trabalhos, foram colhidos os depoimentos das testemunhas PC PAULO AFONSO CARDOSO e PC MARCIO LUIZ TEIXEIRA DE CAMARGO BARHUN.

Após, o réu DARLIN ALVES RODRIGUES foi devidamente interrogado.

O(s) depoimento(s) e o(s) interrogatório(s) foi(foram) captado(s) e gravado(s) em vídeo e a(s) mídias(s) está(ão) disponível(veis) no presente termo, no Sistema SAJ.

A seguir, pela MMª. Juíza foi declarada encerrada a instrução, determinando que as

partes se manifestassem em alegações finais.

Pela Dra. Promotora de Justiça foi dito o seguinte: "DARLIN ALVES RODRIGUES, já qualificado nos autos em epígrafe, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pelas condutas delituosas descritas na exordial acusatória de fls. 98/101. O processo teve andamento regular. Devidamente notificado (fls. 122), o réu apresentou sua defesa preliminar (fls. 135/139), sendo a denúncia recebida (fls. 140/142). Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e o réu, por fim, interrogado. Em síntese, o necessário. Passa-se à manifestação. A prova produzida impõe a procedência da ação penal. A materialidade delitiva está consubstanciada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 31, fotografia de fls. 32 e pelo laudo de exame químico toxicológico definitivo de fls. 90/92. A autoria do crime de tráfico de drogas descrita na denúncia restou também suficientemente comprovada. O policial civil Paulo Afonso Cardoso, confirmando suas declarações prestadas na fase investigativa, narrou que, na data dos fatos, realizavam investigação visando ao combate ao comércio ilícito de entorpecentes no bairro Paulicéia, local já conhecido como ponto onde ocorre o comércio ilícito de entorpecentes. Disse que seu colega Bahrum permaneceu em observação discreta, em viatura descaracterizada, em um ponto estratégico. A testemunha e outros policiais permaneceram a distância. Depois de alguns minutos seu colega entrou em contato narrando que havia visualizado um indivíduo ocultando algo em um bueiro e de lá pegando algo, conduta suspeita, informando suas características físicas e de vestimentas. Assim, dirigiram-se até o local e avistaram o acusado, que permanecera sob observação do policial Bahrum, para evitar qualquer fuga. Abordaram então o acusado e realizaram pelo local onde ele estava e o bueiro onde ele mexia. No bueiro localizaram um saco plástico contendo 28 porções de maconha e, no local onde o acusado havia se abaixado e jogado algo, na calçada, localizaram 09 porções de maconha. Em poder do acusado foi localizada a quantia de setenta reais. No mesmo sentido foram as palavras do policial civil Márcio Luiz Teixeira De Camargo Barhun, que acrescentou que na sua observação velada viu nitidamente o acusado entrando em um bueiro, lá colocando um pacote plástico branco e depois o réu saiu e colocou a grade de volta e foi para outro local, onde se abaixou na calçada e jogou algo no chão. Relatou que continuou realizando o trabalho de observação, já que evidenciado o comportamento suspeito do acusado, sendo certo que, então, em dado momento, surgiu um transeunte que se aproximou do réu e, claramente, o depoente visualizou que entre os indivíduos houve movimento de troca, tendo o réu se abaixado no chão e apanhado algo no chão, no mesmo local onde ele havia antes jogado algo. Ante a suspeita conduta, acionou seu colega de serviço Cardoso, que estava com viatura caracterizada nas proximidades, e ele foi até o local e realizou a abordagem. Disse que não participou da ação de abordagem, no entanto, percebeu que seus colegas encontraram algo no chão, no mesmo local onde o réu estava e se abaixou, e, ainda, observou que os policiais entraram no bueiro, encontraram um saco plástico de cor branca. Disse que foi informado que no local onde o acusado se abaixava na calçada havia 09 porções de maconha, enquanto no interior da sacola que estava no bueiro, foram encontradas outras 28 (vinte e oito) porções de maconha. Por fim, interrogado, o réu negou os fatos a si atribuídos, alegando que não estava realizando a venda de drogas no local. Disse que é usuário e que os policiais o abordaram querendo saber quem era o traficante. Disse que não contou o nome do traficante, pois não é cagueta, e que os policiais o agrediram e apareceram com as porções de maconha. Disse que no dia que foi preso estava apenas com uma porção de crack e um cachimbo. Assim, em que pese a negativa do réu quanto aos fatos, sua versão não deve prevalecer, vez que dissonantes e isoladas das demais provas coligidas nos autos, não encontrando nelas qualquer respaldo. De fato, é certo que os policiais civis foram uníssomos ao afirmar que o acusado foi flagrado em típica conduta de tráfico, escondendo algo, que posteriormente foi verificado se tratar de uma sacola plástica contendo as porções de maconha, dentro de um bueiro, bem como jogando o resíduo das porções na calçada, porções essas que também foram apreendidas e, por fim, foi visto atendendo um transeunte, para quem entregou algo e dele recebeu dinheiro. Por fim, as

imagens contidas no link de fls. 146 corroboram a versão apresentada pelos investigadores e não deixam dúvidas de que, realmente, o acusado estava promovendo o tráfico de drogas no local dos fatos. Vale ressaltar, por oportuno, que os depoimentos prestados pelos policiais são plenamente válidos como meio de prova, se produzidos sob o crivo do contraditório e se estiverem coerentes com as demais provas produzidas, como ocorre no caso em tela. Nesse sentido já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça, nos termos do voto do Ministro Arnaldo Esteves Lima, no julgamento do HC nº 123293/MS, publicado no dia 16/11/2009, do qual se extrai o seguinte trecho: O depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de prova. Ainda nesse sentido: PROVA - TESTEMUNHA - Depoimento de agentes policiais - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - Análise que se faz em cada caso concreto - Inexistência de dúvida que justifica o decreto condenatório - O testemunho de policiais, que no cumprimento de sua missão atuam na repressão penal, é tão válido como de qualquer outro testemunho - Merecem credibilidade e se de acordo ou conformidade com as demais provas, justificam um decreto condenatório - Entendimento - Precedentes - Recurso parcialmente provido. (Apelação n. 990.08.180251-1 - Birigui - 16ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Newton de Oliveira Neves - 04/05/2010 - 8640 - Unânime). (Grifei). Destarte, tem-se que o crime descrito na denúncia restou bem comprovado, sendo a condenação de rigor. Quanto à aplicação da reprimenda, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, haja vista que o acusado ostenta maus antecedentes (autos nº 3000560-31.2013 - fls. 114/115; e 0017774-63.2014 - fls. 113/114). Na segunda fase, verifica-se que o réu é reincidente específico (autos nº 0000595-55.2017 - fls. 111). Na terceira fase, ante a reincidência, inaplicável o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Requeiro, por fim, seja decretado o perdimento do valor apreendido com o acusado, consistente em R\$ 70,00 (setenta reais), com fulcro nos artigos 61 e 63, ambos da Lei nº 11.343/2006, e no artigo 243, parágrafo único, da CF/88. Diante do exposto, o Ministério Público requer e aguarda a procedência da ação, com a condenação do acusado nos exatos termos da exordial".

Pela Defesa foi dito o seguinte: "MM. Juíza, o acusado foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, na forma como descrito na exordial. Encerrada a instrução probatória nesta data, a Defensoria Pública entende que as provas levadas aos autos não autorizam a prolação de um édito desfavorável ao denunciado, razão pela qual deverá ocorrer a ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. Isso porque, como se sabe, a Constituição Federal garante a presunção de inocência, de tal sorte que se faz necessário um conjunto probatório robusto e harmônico para que se autorize a prolação de um decreto condenatório. Nesta data, a testemunha Marcio, Policial Civil, declarou que estava fazendo uma investigação velada no local, conhecido como ponto de tráfico. Visualizou uma pessoa dentro do bueiro, deixando um saco plástico no local. Quando ele saiu, foi a outro local, em uma calçada, e deixou um outro objeto nessa calçada. Depois, ele conversou com um transeunte, oportunidade na qual efetuou uma filmagem da manifestação. Chamou a equipe e a viatura apareceu e abordou o réu. Nos locais indicados pela testemunha (calçada e um bueiro), foram achadas as drogas descritas na denúncia. O acusado negou a prática do crime. Não o conhecia. A testemunha Paulo, Policial Civil, declarou que o local dos fatos é conhecida como ponto de tráfico. No dia da prisão do réu, decidiram investigar a dinâmica que ocorria na rua, por isso dividiram a equipe e o parceiro da testemunha ficou em um ponto estratégico, fazendo a observação do local, enquanto a testemunha permaneceu em local próximo. Pouco tempo depois, recebeu uma comunicação do seu parceiro de que uma pessoa estaria em condutas que indicavam o tráfico de drogas, passando as suas características. Foram ao local e efetuaram a abordagem do réu. Quando ele foi abordado, localizaram R\$ 70,00 em dinheiro em seu poder. Indagado sobre o dinheiro, ele disse apenas que a quantia lhe pertencia. Passou a fazer uma busca nos locais da via pública onde o parceiro da testemunha teria visualizado condutas de

ocultação de droga. Nos dois pontos onde o réu havia manuseado, encontraram, numa calçada em manutenção, 09 porções de maconha. Além disso, junto a um bueiro, que possui uma grade móvel e onde o réu teria entrado, localizaram uma sacola contendo mais 28 porções de maconha. O réu, então, disse que a equipe estaria “forjando” as drogas e negou qualquer envolvimento no tráfico. O parceiro da testemunha também apresentou as filmagens que estão juntadas nos autos. Não conhecia o réu antes dos fatos. O réu, em interrogatório, declarou que estava recolhendo reciclagem e vendeu um móvel no ferro-velho, oportunidade na qual recebeu R\$ 65,00. Quando foi embora do ferro-velho, os Policiais estavam abordando as pessoas no local. Eles queriam que o acusado fornecesse o endereço de uma “casa-bomba”. Esses fatos aconteceram antes do dia 09 de agosto. No dia 09, foi novamente abordado. Os Policiais chegaram e o agrediram, dizendo que queriam saber o nome do traficante, mas não poderia informar isso a eles. Tinha comprado apenas uma pedra de crack e portava um cachimbo e um acendedor. Foi colocado na viatura e levado até sua residência, mas sua vizinha não deixou que entrassem no imóvel. O restante das drogas foi encontrado nos fundos da rua, em uma travessa. Portanto, Excelência, o acusado nega a prática dos fatos. Sua negativa deve ser considerada um elemento probatório, afastando-se qualquer juízo preconceituoso que se tenha contra ela, sobretudo porque não refutada pelas demais provas dos autos. Isso porque, as provas produzidas pela acusação restringem-se, apenas, às palavras dos Policiais responsáveis pela prisão do acusado, as quais, todavia, devem ser recebidas com reservas. Com efeito, mister destacar, neste ponto, que a Defensoria Pública não pretende desqualificar a nobreza ou a honestidade de uma instituição responsável pela segurança pública do Estado ou negar a força probatória dos depoimentos dos agentes, embora seja inegável que eles, na grande maioria das vezes, ratifiquem em Juízo a versão apresentada quando da realização da prisão, inclusive como forma de convalidar o ato e seus respectivos efeitos. Sustenta a Defensoria Pública, na realidade, que os depoimentos dos agentes, sem amparo de outras provas que estejam ao alcance dos órgãos responsáveis pela persecução penal, não podem servir de fundamento para a prolação de uma sentença condenatória, sob pena de se atribuir à referida prova caráter quase absoluto no processo penal, fragilizando as garantias do devido processo legal e da ampla defesa, bem como inviabilizando a busca da verdade processual. Aliás, em se tratando de delitos de drogas, o E. Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de não admitir as palavras de Policiais ou outros agentes de segurança como fundamento para uma condenação: “Assim, o que se verifica, é que a condenação foi amparada exclusivamente nas declarações policiais, o que se revela insuficiente. É que seus testemunhos tem qualificação e natureza diversas de qualquer outro. São relatos de agentes policiais, ou seja, a longa manus do próprio aparelho repressor, de modo que as teorizações jurídicas processuais de âmbito criminal não podem ignorar a realidade fática. O policial é o agente operacional da repressão e não depõe com a imparcialidade das demais testemunhas, ainda que de modo inconsciente. Sua visão sobre os fatos, o seu entendimento sobre as circunstâncias que apurou, são do próprio sistema repressor, dos quais o garantismo constitucional do devido processo legal objetiva proteger.” (TJSP – 7ª Câmara Criminal - Ap. 0020153-57.2006.8.26.0224 -- Rel. Francisco Menin – j. 03/02/11 - grifado). Inclusive, no caso em pauta, verifica-se que, a despeito das declarações dos Policiais e da “movimentação suspeita” supostamente visualizada, não é possível afirmar, com certeza, que as condutas se tratavam efetivamente de um ato de venda de drogas, eis que os supostos compradores não foram apresentados na Delegacia de Polícia e não existem outras testemunhas presenciais dos fatos. Além disso, as substâncias não estavam sob a posse direta do acusado, eis que seu encontro ocorreu em um local aberto, de livre acesso a qualquer indivíduo. Ressalta-se, ainda, que a mera afirmação de que o endereço da abordagem seria conhecido como um “ponto de tráfico” não é presunção absoluta do envolvimento do réu na prática do crime, eis que, nesses lugares, circulam tanto indivíduos que se dedicam ao comércio de drogas quanto usuários das substâncias. E o vídeo juntado aos autos também não demonstra, efetivamente, a vinculação do réu ao tráfico, eis que se trata de uma gravação efetuada a uma grande distância e o contato do acusado com o outro indivíduo foi muito breve, sendo perfeitamente

plausível que a medida, na realidade, fosse um ato de compra de drogas por parte do réu (mencionando-se, ainda, que a filmagem não mostra o réu mexendo nos locais onde as drogas foram encontradas). De outra parte, também é importante observar a alegação do réu de que foi vítima de agressões praticadas pelos agentes responsáveis por sua prisão, sendo que o laudo de exame de corpo de delito cautelar juntado aos autos indica a ocorrência de lesões compatíveis com indícios de agressão e o próprio Magistrado que presidiu a audiência de custódia também determinou que eventuais excessos fossem apurados, o que fragiliza ainda mais o depoimento das testemunhas. Portanto, diante das provas produzidas, a absolvição do réu é medida de rigor, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Entretanto, na hipótese deste E. Juízo afastar o pleito absolutório, requer-se, ao menos, diante das declarações do acusado em seu interrogatório, a DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA O TIPO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. Isso porque, com a devida vênia, há de se reconhecer que não há nos autos indícios de que o acusado fosse comercializar as drogas apreendidas, sendo que, reitere-se, não foi verificado qualquer ato efetivo de mercancia dos entorpecentes. Assim, no máximo, o réu poderia ser responsabilizado por portar drogas para fins de consumo pessoal, pois não foi demonstrado cabalmente o intuito lucrativo, não bastando a simples apreensão do entorpecente em poder do acusado para se justificar uma condenação por tráfico. Vale observar, ainda, que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas em poder do réu nada diz quanto à sua destinação, eis que a quantidade necessária para a satisfação de um usuário é completamente variável. Para a configuração do crime de tráfico, não basta a simples apreensão da droga, sendo imprescindível a aferição de prova cabal da finalidade de mercancia dos entorpecentes por parte do réu, o que não foi o caso. Todavia, caso mantida a condenação pelo tráfico de drogas, requer-se, então, a APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06, MESMO EM FACE DA REINCIDÊNCIA. Isso porque, ainda que considerado reincidente, vale lembrar que a Lei de Drogas, ao fixar como pena mínima, para o delito de tráfico, cinco anos de reclusão, prevendo, ainda, a causa de diminuição de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) para primários, acaba por valorizar, em demasia, o critério da reincidência. Desde, portanto, que presentes os outros requisitos para a aplicação da causa de diminuição (ou seja, não havendo elementos probatórios de que o réu se dedique ao crime, praticando-o com contumácia, e sem provas de que ele integre organização criminosa), é de se considerar que o peso atribuído à reincidência é superdimensionado em relação ao apenamento do agente primário, ofendendo, assim, o princípio da proporcionalidade, implícito no ordenamento constitucional do Estado Democrático de Direito, que tem como fundamento a dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, CF).

A aplicação da pena ao réu primário, presentes os demais requisitos legais, ensejaria a redução no patamar de 2/3, implicando a sanção de um ano e oito meses de reclusão. Ao réu reincidente, o mesmo fato representaria, pela ausência de aplicação da causa de diminuição, uma pena de 5 (cinco) anos. O peso da reincidência, portanto, é claramente desproporcional, pois o valor do fato praticado é de aproximadamente 1/3 (um terço) da pena, sendo 2/3 (dois terços) aplicados em função da reincidência. Essa desproporção também é inconstitucional porque atribui, para a dosagem da pena, valor maior aos fatos pretéritos do que à própria acusação em questão. Aceitar-se como válida a ampliação ao infinito do peso da reincidência implica a aplicação do direito penal do autor e não do fato – punição fundada preponderantemente em quem o agente é (ou seja, em face de seus antecedentes) e não em função do ato por ele praticado. Como afirma Muñoz Conde: “A distinção entre Direito Penal do ato e Direito Penal do autor não é só uma questão sistemática, mas, também, e fundamentalmente, política e ideológica. Só o Direito Penal baseado no ato cometido pode ser controlado e limitado democraticamente (...) o Direito Penal do autor não permite limitar o poder punitivo do Estado e favorece sua concepção totalitária” (Teoria Geral do Delito – SAFe, p. 09/10). O direito penal do autor não se coaduna com o Estado Democrático de Direito e por isso suas impressões devem ser descartadas, inclusive pelo Juiz. No mesmo sentido: “O direito penal de autor não encontra guarida em nenhum sistema penal fincado no Estado de

Direito, comprometido, que é, com a dignidade da pessoa humana e com a garantia de seus direitos fundamentais, e, sobretudo, em nosso ordenamento, onde a presunção vigente é, ao reverso do que se propugna com a referência a tal condenação, a de inocência." (Min. Cezar Peluso em Voto Visto no RHC 81.057-8-SP). Por fim, nem se diga da impropriedade de se afastar uma regra legal (proibição da redução ao reincidente) em face de um princípio não explícito. Como afirma Fábio Konder Comparato, apesar de seu alto grau de abstração, os princípios são normas jurídicas e não simples recomendações programáticas ou exortações políticas. Mais ainda: trata-se de normas jurídicas de eficácia plena e imediata, a dispensar a intermediação de regras concretizadoras. Provocado ou não pelas partes, o juiz está sempre autorizado a aplicar diretamente um princípio ao caso trazido ao seu julgamento, por força do disposto no §1º do art. 5º, da Constituição ("O papel do juiz na efetivação dos direitos humanos", in Direitos Humanos - Visões Contemporâneas, edição de Associação Juizes para a Democracia, 2001). Por fim, caso não sejam acolhidas as teses anteriores, a defesa requer, no tocante à dosimetria da pena: (i) a fixação da pena-base no patamar mínimo previsto na lei, ressaltando-se a pouca quantidade e diversidade de entorpecentes apreendida, sendo que as demais circunstâncias previstas no art. 59 do CP são favoráveis ao acusado, ressaltando-se que a sua vida pregressa deve ser valorada somente na segunda fase, a fim de se evitar eventual bis in idem com eventual agravante da reincidência; (ii) a incidência, na terceira fase da dosimetria, do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, como sustentado; (iii) seja fixado o regime menos gravoso do que o fechado para início do cumprimento da pena, considerando o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, que impunha, obrigatoriamente, o início do cumprimento da pena no regime fechado, em relação aos crimes hediondos e os a ele equiparados (STF - Pleno - HC nº 111.840/ES - rel. Min. Dias Toffoli), em atenção, ainda às súmulas nº 718 e 719, do E. STF e das súmulas nºs 269 e 440 do E. STJ e, ainda, em razão do disposto no art. 387, § 2º, do CPP; (iv) seja concedida ao acusado a possibilidade de aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade, haja vista a inexistência de fato concreto que autorize, neste momento processual, a manutenção de sua prisão preventiva".

A seguir, pela MMª. Juíza foi proferida a Sentença a seguir:

"Vistos.

DARLIN ALVES RODRIGUES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 09 de agosto de 2022, por volta das 10h00min, na Rua Vasco da Gama, nº 284, Bairro Pauliceia, nesta cidade e comarca de Piracicaba, trazia consigo e tinha em depósito, para inequívocos fins de comercialização a terceiros, 37 (trinta e sete) porções de maconha, pesando aproximadamente 52,9g (cinquenta e dois gramas e nove decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Narra a denúncia que policiais civis realizavam investigação a fim de combater o comércio ilícito de entorpecentes no local dos fatos, já conhecido como ponto de venda de drogas. Enquanto um dos policiais permaneceu na viatura caracterizada, seu colega passou a realizar observação discreta no local, tendo, em dado momento, visualizado o réu, que trajava bermuda listrada, jaqueta na cor cinza, boné e chinelo, entrando em um bueiro, manipulando um pacote de grande volume e, em seguida, saindo bueiro e colocando a grade de proteção de volta. Em seguida, o acusado caminhou até outro local na mesma calçada, onde se abaixou e jogou algo no chão. Logo em seguida, um transeunte se aproximou do réu, que pegou algo do chão e entregou ao transeunte, o qual, por sua vez, entregou algo a DARLIN. Ante a suspeita conduta apresentada, o policial à paisana informou os fatos ao seu colega, que rapidamente se dirigiu até onde estava o acusado e o abordou. Em revista pessoal, o policial encontrou em poder de DARLIN a quantia de R\$ 70,00 em notas diversas. No local onde o acusado havia se abaixado, jogado algo ao solo e de onde havia pegado algo e entregue ao transeunte, os policiais localizaram 09 porções de maconha e, dentro do bueiro onde havia o acusado entrado, foram encontradas outras 28 porções de maconha, idênticas àquelas encontradas na calçada ao lado do réu. O réu foi notificado nos termos do art. 55 da Lei nº 11.343/06 (fls. 122) e

apresentou defesa preliminar (fls. 135/139), seguindo-se a decisão que recebeu a denúncia (fls. 140/142).

Designada audiência, foram ouvidas duas testemunhas e interrogado o acusado.

As partes apresentaram alegações finais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

1. A prova dos autos é suficiente e segura ao apontar a responsabilidade penal do réu.

A materialidade do crime está comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 31, pelas fotografias de fls. 32, 43, 44, 46 e 47, e pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 90/92, que trouxe resultado positivo para maconha.

A autoria também é certa.

Por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante, o réu negou a prática do delito. Disse que era usuário de drogas e que havia comprado uma porção de droga para consumo próprio. Afirmou que desconhecia o proprietário das drogas apreendidas.

Em juízo, voltou a negar a prática do crime. Disse que estava vindo de umas casas onde coloca sacos de reciclagem. Afirmou que se deslocava recolhendo reciclagem e, quando descia a Travessa Esplanada, bateu na casa da sua freguesa, que lhe ofereceu um objeto enferrujado. Então, levou ao ferro velho e recebeu R\$ 65,00. Quando estava descendo, foi abordado pelos policiais, que lhe falaram que iriam lhe dar alguns dias para indicar uma casa bomba. Alegou que, no dia 09, foi abordado pelo Deic e agredido. Afirmou que é usuário de "crack", tinha um cachimbo e um acendedor, mas não podia indicar o traficante. Sustentou que os policiais encontraram o restante da droga em outra rua, numa outra biqueira.

A versão apresentada pelo réu, porém, foi infirmada pela prova produzida.

Com efeito, o policial civil Márcio Luiz relatou que fazia investigação velada em local conhecido como ponto de tráfico. Atestou que avistou uma pessoa dentro de um bueiro, onde deixou uma sacola. Asseverou que, na sequência, foi até a calçada e jogou algo. Após, pegava algo na calçada, fazia contato com as pessoas e recebia algo. Então, acionou a equipe, que abordou o acusado e vistoriou a calçada e o bueiro, localizando o entorpecente.

O policial Paulo relatou que a Rua Vasco da Gama é recorrente pela prática de tráfico e já houve várias prisões no local. No dia dos fatos, seguiram para o local para investigação e dividiram a equipe, sendo que o policial Barhun permaneceu em ponto estratégico, em viatura descaracterizado, enquanto o restante dos policiais ficou afastado em viatura caracterizada. Atestou que, após alguns minutos, o policial Barhun comunicou que identificou pessoa em conduta de armazenamento e venda de drogas, fornecendo as características do indivíduo. Então, a equipe seguiu para o local, enquanto Barhun permaneceu com o investigado em seu raio de visão. Disse que o indivíduo foi abordado e, nas suas vestes, encontraram R\$ 70,00. Declarou que passou a fazer busca em locais onde Barhun tinha visto o indivíduo acessado, uma calçada em manutenção, onde encontrou nove invólucros de maconha, e um bueiro, com grade móvel, no qual acharam uma sacola contendo mais vinte e oito invólucros de maconha, idênticos aos demais. Asseverou que o réu negou a posse do entorpecente e alegou que estava sendo forjado.

É de se asseverar que o simples fato de as testemunhas de acusação serem policiais civis não é o bastante para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas. Não estando impedidos, seus depoimentos serão considerados como o de qualquer testemunha, já que nenhuma razão tinham para falsear a verdade, a não serem cumpridores de seus deveres funcionais.

E "como toda testemunha o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale não pela condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se tratar de policial" (RJTJESP 125/263). Nesse mesmo sentido: RT 591/313, 612/316 e 654/278.

A prova acusatória consistente em depoimentos de policiais é tão válida quanta outra qualquer, desde que tais testemunhos sejam insuspeitos, sérios e coerentes.

Acrescento que a presunção de imparcialidade, retidão e lisura deve ser em favor da autoridade pública, que age no estrito cumprimento do dever legal (cf. RT 738/665). Enfim, o fato de os policiais civis, durante campanha, terem flagrado o réu em conduta típica de tráfico, entregando a um transeunte algo que tinha acabado de retirar de um pacote escondido dentro de um bueiro e jogado ao chão, vindo a localizar R\$70,00 na posse dele, nove porções de maconha jogadas no chão e 28 porções da mesma droga dentro do bueiro, o que não foi infirmado por nenhum elemento de prova, conduz à certeza quanto a autoria e à destinação do entorpecente ao comércio ilícito.

Anoto que a quantidade de entorpecentes apreendida e a forma como estavam acondicionados, aliados ao local dos fatos, conhecido como ponto de venda de drogas, e às circunstâncias da apreensão - foram flagrados atos típicos da traficância, deixam mesmo evidente que a droga se destinava ao comércio ilícito. Sobre a viabilidade desses elementos demonstrarem a destinação comercial dos entorpecentes, cito os seguintes precedentes:

"Apelação. TRÁFICO DE DROGAS. Conjunto probatório firme e coeso para manter a responsabilização do réu, notadamente pelos relatos dos policiais e a existência de denúncias anônimas apontando o réu como sendo traficante de drogas. Quantidade e forma de acondicionamento que demonstram a destinação das drogas para a mercancia. Penas. Redução. Possibilidade - Regime prisional incensurável PARCIAL PROVIMENTO AO APELO." (TJ-SP: Apelação Criminal nº 0004053-31.2010.8.26.0242, 10ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Rachid Vaz de Almeida, j. 16/02/2012, v.u.).

"APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Inconformismo defensivo. - Materialidade e autoria comprovadas. Relatos dos policiais que encontraram drogas em posse do réu - Quantidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes que não deixam dúvidas da narcotraficância - Condenação mantida - Penas bem dosadas que não comportam reparo. Recurso desprovido." (TJ-SP: Apelação Criminal nº0038185-16.2007.8.26.0050, 8ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Camilo Léllis, j. 26/04/2012, v.u.).

Consigno, outrossim, que o fato de o acusado ser usuário de entorpecentes, por si só, não infirma a acusação.

Com efeito, é comum que as figuras do usuário e do traficante se encontrem na mesma pessoa, eis que, muitas vezes, o usuário se vale do comércio ilícito de drogas para angariar recursos como meio de sustentar o uso, não ficando, com isso, isento de responsabilidade pela prática do crime de tráfico.

Nesse sentido: "A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura de traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (TJSP - RJTJSP, 101/498).

Na mesma esteira o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça: "(...) muito embora o acusado tente se apresentar como mero usuário, é sabido que nada impede que possam coexistir, numa mesma pessoa, as duas figuras - usuário e traficante - daí, pois, ainda que no caso focado o agente seja usuário, restou demonstrado que o mesmo praticava conduta dirigida para a vontade de traficar ilicitamente substância entorpecente" (STJ - REsp 1708569, Rel. Min. Ribeiro Dantas, data de publicação: 06.03.2018).

Impõe-se, portanto, a condenação do réu como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

2. Passo, pois, à fixação da pena, observando o critério trifásico estatuído no art. 68 do Código Penal.

Atendendo às circunstâncias do art. 59 do referido diploma legal, observo que o réu é reincidente (fls. 111/115). Entretanto, essa circunstância só pode ser considerada na segunda fase de fixação da pena, evitando-se bis in idem. Assim, irrelevantes as demais circunstâncias, fixo a pena base em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, no seu valor mínimo legal.

Na segunda fase de fixação da pena, está presente a agravante da reincidência, inclusive específica (autos nº 0000595-55.2017 desta 4ª Vara Criminal, nº 00177774-63.2014 da 2ª Vara Criminal local e nº 3000560-31.2013 da 1ª Vara Criminal do Foro de São Pedro -fls. 111/115), razão pela qual aumento-a de um quinto, resultando seis anos de reclusão e seiscentos dias-multa.

Inexistem causas de aumento e, por ser reincidente, inclusive, específico, não faz jus o réu à redução prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

Quanto ao regime inicial para cumprimento da pena, fixo o fechado, em decorrência da reincidência específica e por ser o único compatível com a natureza do delito, equiparado a hediondo.

Não é demais consignar que as nefastas circunstâncias e consequências que o crime de tráfico de entorpecentes causa à sociedade conclamam a fixação do regime mais gravoso, a fim de que se retire o infrator do convívio social, evitando que ele continue a exercer tais atividades ilícitas, viciando pessoas e destruindo famílias.

Nesse sentido os recentes julgados do E. Tribunal de Justiça deste Estado: Apelação nº 0001994-15.2011.8.26.0443, 4ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Luis Soares de Mello, j. 26.06.12, e Apelação nº 0011197-28.2006.8.26.0038, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Roberto Midolla, j. 28.06.12.

Veda-se, por fim, o direito de apelar em liberdade, eis que permanecem inalterados os motivos que ensejaram a custódia cautelar, a qual não pode ser tornada insubsistente, sobretudo em razão da superveniência de sentença condenatória pela prática de crime equiparado a hediondo.

Nesse sentido já decidiu o E. Tribunal de Justiça: "Conforme já sedimentado nos Tribunais Superiores, o normal daquele que respondeu o processo preso cautelarmente é que assim permaneça ante a superveniência de sentença penal condenatória e diante da inexistência de qualquer elemento que modifique sua situação processual". (HC nº 0035894-52.2014.8.26.0000, Relator Des. Alex Zilenovski, julgado em 04.08.2014, V.U.).

Confira-se, ainda, recente julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a custódia cautelar" (HC nº 283948/SP, 5ª Turma, Relator Ministro Jorge Mussi, julgado em 06.05.2014, V. U.). Comprovada a origem ilícita do dinheiro apreendido, declaro seu perdimento.

3. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, CONDENANDO o réu DARLIN ALVES RODRIGUES, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, "caput", da Lei 11.343/06, à pena de seis anos de reclusão e seiscentos dias-multa, no valor unitário mínimo, fixado o regime fechado para início do cumprimento da pena e vedado o direito de apelar em liberdade.

Recomende-se o réu no cárcere em que se encontra preso e, após o trânsito em julgado, procedam-se às anotações e comunicações necessárias.

Declaro perdido o dinheiro apreendido.

Custas na forma da Lei nº 11.608/03.

Publicada em audiência, registre-se, intime-se, comunique-se, expedindo-se o mais necessário".

Pelo(a) Representante do MP foi dito que NÃO DESEJA RECORRER da sentença.

Pelo RÉU foi dito que DESEJA RECORRER da sentença ora proferida.

Pela DEFESA foi dito que DESEJA RECORRER da sentença ora proferida.

A seguir, pela MMª. Juíza foi deliberado o seguinte:

"1) Tendo em vista a EXPRESSA RENÚNCIA do(a) Dr(a). Promotor(a), dou a sentença por TRANSITADA EM JULGADO nesta data, para o MINISTÉRIO PÚBLICO.

2) Recebo o recurso interposto.

3) Intime-se a Defensoria Pública para que apresente razões de apelação.

4) Juntadas as razões, dê-se vista ao MP para contrarrazões de recurso.

5) Expeça-se Guia de Recolhimento e Internamento Provisória.

6) Com as razões e contrarrazões de apelação, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça, com as cautelas de praxe, salientando que o termo final da prescrição é 11/12/2034.

Saem os presentes intimados".

CERTIFICO e dou fé que em sendo a audiência realizada virtualmente e havendo sido o presente termo de audiência lido, achado conforme pelas partes e assinado eletronicamente pela MM^a. Juíza de Direito da 4^a Vara Criminal da Comarca de Piracicaba/SP, dispensam-se as assinaturas das eventuais testemunhas e vítimas, visto que os depoimentos são gravados em mídia. NADA MAIS. Eu, Diego Ricardo Lopes Cardoso Da Cruz, digitei.

Gisela Ruffo
JUÍZA DE DIREITO
[Assinado eletronicamente]